

SENTENCIA NUMERO:111

En la ciudad de Córdoba, a diez días del mes de septiembre de dos mil uno, se reunieron en Acuerdo Público los señores Vocales de la Excma. Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, con el objeto de dictar sentencia en los autos caratulados: **"RENOVELL FRANCISO F. C/ PATRICIO LINARES -EJECUTIVO-",** venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia y Cuadragésimo Primera Nominación en lo Civil y Comercial, en contra de la sentencia número 18 de fecha 1.03.01, dictada por Señor Juez Dr. Jorge Eduardo Arrambide, que resuelve: "1) No admitir la prejudicialidad planteada. 2) Rechazar la excepción planteada por el demandado. 3) Mandar llevar adelante la ejecución iniciada por Francisco F. Renovell en contra de Patricio Linares hasta el completo pago de la suma de pesos tres mil setecientos con más los intereses previstos en el considerando respectivo desde la presentación del cobro de los documentos y hasta su efectivo pago. 4) Costas a cargo del demandado. 5) Regular los honorarios profesionales del Dr. Oscar Sánchez Brondo por la labor desarrollada en los presentes, en la suma de pesos novecientos cuarenta. Protocolícese,...".-----
-----**¡Error! Marcador no definido.**

Este Tribunal en presencia de la actuario se planteo las siguientes cuestiones a resolver: 1) ¿Es procedente el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada? 2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-----

Realizado el sorteo de ley la emisión de los votos resultó en el siguiente orden: Dr. Armando Segundo Andruet (h), Dra. Nora Lloveras y Dr. Abraham Ricardo Griffi.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H) A LA PRIMERA CUESTION

PLANTEADA DIJO: I.- En contra de la sentencia N° 18 del 1.III.01, dictada por el Sr. Juez Sustituto de Primera Instancia y Cuarenta y Una

Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Jorge Eduardo Arrambide, interpone recurso de apelación la parte demandada que le fuera concedido mediante proveído de fs. 137 vta.-----

Radicados los autos en la Alzada e impreso el trámite de ley, expresó agravios a fs. 142/145 vta., que fueran contestados por la actora a fs. 148/149 vta; habiendo quedado firme el decreto de autos (fs. 149 vta.) ha quedado la causa en estado de ser resuelta.-----

II.- La sentencia apelada contiene una relación de causa que satisface las exigencias de los arts. 329 y 330 del CPC, razón por la cual a ella me remito a efectos de abreviar.-----

El recurrente y parte demandada por su propio derecho Dr. Patricio Linares Sullivan, se queja diciendo que el a quo, no ha tenido en cuenta para fundar su sentencia en la negativa de la deuda formulada por el suscripto y en el carácter doloso de la tenencia de los valores por parte del actor. Tampoco ha tenido en cuenta, de que el actor carece de la acción ejecutiva en el caso de que nos ocupa. Señala en manera particular y transcribe, el art. 63 de la ley de cheques N° 24.452 y de ella obtiene como conclusión que en ella, no se menciona expresamente en el dispositivo legal vigente; de que la certificación efectuada conforme a la reglamentación -es decir copia auténtica del valor- de que se le adjudique acción ejecutiva, sólo menciona las acciones civiles. Si el legislador quiso otorgarle la acción ejecutiva a esa constancia -tal la presentada como base de esta acción- debió habérselo otorgado expresamente, lo cual dice que se hizo. Confronta lo dicho, con el art. 38 del texto citado y encuentra razones que lo ratifican en la posición sostenida.-----

Agrega luego que "Al no habersele otorgado expresamente en la ley 24.452 la acción ejecutiva a la fotocopia autenticada del cheque devuelto por

la Institución girada por orden de no pagar por haber sido extraviado o sustraído y no estar contemplado en el art. 518 del CPC aquélla, la excepción tal como ha sido planteada debió prosperar. Mas aun, si a ello le sumamos de que el actor no es tenedor legítimo y que no ha protestado en forma los valores al no haber realizado gestiones extrajudiciales tendientes a su cobro.-----

Finalmente señala que carece de legitimación alguna el actor, por ser tenedor doloso y por ende de mala fe, carece de acción ejecutiva por carecer de título para ello -por no otorgarlo la ley y por no haber protestado los valores en forma-. Debo hacer notar que el inferior ha acogido una ejecución sin que se le hayan adjuntado los títulos que manda a pagar. Ha hecho lugar a la ejecución con sólo las fotocopias de los valores con una simple fotocopia -por más autenticada que esté- le ha otorgado la acción ejecutiva al actor. Lo que demuestra que no sólo la excepción de inhabilidad de título debió prosperar; sino que todo el proceso es nulo de nulidad absoluta por incumplimiento de lo prescripto en el art. 517 del CPC.-----

A su turno la parte actora por intermedio de su letrado patrocinante Dr. Oscar Sánchez Brondo, contesta la expresión de agravios, solicitando la confirmación en todas sus partes de la sentencia recurrida.-----

III.- Los agravios que la parte demandada ha denunciado a la sentencia de la anterior instancia son dos. Por una parte, dice que el art. 63 de la ley de cheques vigente (24.452 y su modificatoria posterior 24.760), que por caso tutela lo referido a los supuestos de oposición al pago de los cheques originados en denuncia penal del librador o tenedor; impone que la entidad girada entregue a quien presentara el cheque una certificación con la cual se habilitaran las acciones civiles; 'acción

civil' que entiende no resulta asimilable a 'acción ejecutiva' y por lo cual, la inhabilidad de título que ha sido deducida debió ser atendida en la anterior instancia. Por otra parte y como segundo agravio, dice, que se ha acompañado sólo una fotocopia autenticada del título ejecutivo (fs. 3) y no el título ejecutivo y ello como tal, importa la nulidad de todo el proceso ejecutorio que fuera cumplido.-----

Ninguno de los dos agravios pueden ser atendidos. En primer lugar se impone señalar, que deviene como una reflexión tardía la que la parte recurrente realiza al incursionar en el segundo de los agravios que han sido enunciados por nosotros. Pues a tal respecto basta con advertir que el mencionado tópico, no ha sido objeto de denuncia alguna al momento de la oposición de las excepciones (fs. 24/26 vta) y por lo tanto, no habiendo conformado ello, el mismo thema decidendum es obvio, que tampoco puede ser objeto de apelación alguna, porque antes no lo fuera de la resolución en la anterior instancia.-----

La regla impuesta en manera taxativa por el art. 332 del CPC deja inerte el recurrente sobre la base de dicho argumento.-----

IV.- En orden al segundo de los agravios corresponde puntualizar, que más allá que desde una hermenéutica rigurosamente gramatical del texto de la ley se advierte en primer análisis, que si ella dice 'acciones civiles' no dice 'acción ejecutiva' y por lo tanto, la una no es la otra. Sin embargo el mencionado argumento es de una entidad máximamente provisoria, pues nadie puede dudar que la acción ejecutiva es a la vez una acción civil y en función de ello, pues parece ser que la diferencia que el recurrente ha colocado como eje de su agravio deviene excesivo. El argumento teleológico permite sin duda alguna una respuesta como ha sido elaborada.-----

De cualquier manera no se puede dejar de señalar, que el recurrente a los fines de otorgar fortaleza a su agravio, ha presentado que en otra norma -art. 38, 3er. párrafo ib.- se indica bajo que condiciones 'quedará expedita la acción ejecutiva'; con lo cual intenta mostrar que si en alguna norma de dicho texto legislativo se ha indicado especialmente la conformación de la acción ejecutiva, no hay razón que autorice sostener que -pese a nuestro reparo anterior-, allí donde se indica acción civil se ha querido decir acción ejecutiva. Cuando el legislador ha querido otorgar el mencionado carácter, expresamente lo ha hecho saber.-----

La argumentación vuelve a ser minimizante del problema, y que no sólo que nuestra tesis brindada antes sigue inconmovible como tal; sino que sustancialmente lo que se hace con ella, es no reconocer el debido funcionamiento de la orden de no pago al banco girado por parte de aquél que en el caso era propiamente el tenedor desposeído. A tal efecto, basta con advertir que el Sr. José Ricardo Flachs es quien acompaña la respectiva exposición por extravío entre otros, de los valores que luego son reclamados por la vía ejecutiva, a ello se suma y ya como prueba de la causa, que la mencionada exposición ante la Institución Bancaria girada fue conformada adecuadamente por el propio demandado, tal como resulta ello de la informativa cursada al Banco Río (cfr. fs. 56).-----

El mencionado extremo no es un dato menor, puesto que el Banco girado con ello es impuesto de que no pague los valores que al cobro pueden ser presentados y que han sido objeto de denuncia por extravío o robo. El nombrado tópico, aparece de esta manera sustancial en el análisis, con la orden de no pagar, es el Banco girado quien debe abstenerse de hacerlo porque quien con él se ha vinculado así lo dispone. Mas también hay que señalar con total firmeza que ello en manera alguna puede

modificar lo que como tal deviene inconmovible, con independencia de cualquier notificación que al banco girado se pueda efectuar como es la misma irrevocabilidad del cheque.-----

Ello permite afirmar que el cheque mientras cheque es -o sea no ha caducado-, aunque redundante pueda parecer ello, deviene irrevocable. No existe medio jurídico que obste a la eficacia cambiaria de la declaración unilateral en él documentada una vez que salió de la mano del librador. Como se puede advertir, si el cheque con la orden de no pagar a quien se presente a cobrarlo atento a que dichos valores han sido avisados como extraviados o robados, no altera la sustancia del mismo cheque y por lo cual tampoco, ninguno de los efectos jurídicos que al mismo concierne en riguroso sentido.-----

En manera categórica lo dicho es afirmado por la doctrina y que aun a fuerza de resultar extenso el párrafo, preferimos transcribirlo atento a su importancia. Dice Osvaldo Gómez Leo que "efectuada la pertinente comunicación al banco girado, éste no deberá pagar el cheque en cuestión, pues tal orden de no pago obsta al funcionamiento regular del servicio de caja que presta el banco. Es decir, opera en el ámbito de la relación interna establecida entre el cliente y el banco, de naturaleza contractual, (...), no produce efectos en el ámbito de la relación externa, ni se manifiesta, jurídicamente, como una revocación de la declaración cambiaria; por natural consecuencia de ello, el cheque rechazado con la constancia de que no se ha efectivizado en razón de la 'orden de no pago' dada por el librador o, en su caso, por el tenedor, resulta título ejecutivo hábil para demandar su cobro mediante las respectivas acciones regresivas contra el librador y los endosantes" (Irrevocabilidad del cheque, publicado en LL 1983-B-706).-----

De esta manera entonces corresponde advertir, que por una parte existe la relación interna entre cliente y banco que como tal, es la que deviene afectada con el aviso de no pago; pero que como tal, con independencia de ciertas normas que podríamos nombrada de 'refacción' del título ejecutivo, acorde lo prescribe el art. 5 ib. con más todas aquellas propias que resultan en particular de la Comunicación A-2329 del B.C.R.A. -fotocopia anverso y reverso del título con aviso de no pago, certificada por la entidad girada, etc.-, pues no tiene efectos en la relación externa, donde el régimen normativo no es otro que no sea el que devienen de las normas cambiarias que lo regulan como título de crédito. Entre otras cosas se impone destacar que en el derecho externo, se reconoce en todo cheque una declaración de voluntad unilateral que se caracteriza por ser incondicionada, no recepticia e irrevocable; y pues cuando destacados que es 'no receptiva', afirmamos con ello, que cuenta con eficacia jurídico-cambiaria desde que se exterioriza en forma documental con la firma del librador del cheque, con prescindencia de la adhesión de la voluntad del destinatario (Gómez Leo, O.; Instituciones de derecho cambiario- El cheque, Bs.As., Depalma, 1985, T.III, pág. 23).-----

Reiteramos entonces, que en nada perturba a la entidad de título ejecutivo que se haya dado la orden de no pago de un cheque atento haber sido extraviado el mismo y que el Banco girado así ha cumplido; el cheque es irrevocable y su calidad cambiaria ejecutiva no la pierde hasta tanto y acorde al cumplimiento de las formas propias, hasta tanto el mismo no caduque. Huelga señalar en este orden, que tampoco opera modificación alguna respecto a que la mencionada causal por la cual se torna infructuoso el pago del cheque, sea la del aviso de no pago y no otra diferente, pues el art. 38 de la ley de cheque prescribe "... La constancia consignada por el girado producirá los efectos del protesto.

Con ello quedará expedita la acción ejecutiva que el tenedor podrá iniciar contra librador, endosantes y avalistas".-----

En el caso concreto, basta con advertir que se ha cumplido con el mencionado extremo en ambos cheques, consignándose acorde a la causa porque razón no se paga, asentándose día y hora de ello y la firma autorizada del funcionario respectivo; con ello, reiteramos, se cumplen los efectos del protesto y se abre la vía ejecutiva para el cobro judicial del cheque. La jurisprudencia y doctrina acerca de dicho extremo es pacífica y por lo cual, deviene innecesario hacer indicación precisa.-----

Luego de todo lo que se ha dicho, cabe recordar que el juicio ejecutivo es notoriamente diferente a los demás; al grado tal es ello, que se lo ha nombrado como "el proceso especial, sumario en sentido estricto y de ejecución, cuyo objeto consiste en una pretensión tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales (convencionales o administrativos), que, en razón de su forma y contenido, autorizan a presumir la certeza del acreedor" (cfr. Palacio, L.; Derecho procesal civil, Abeledo Perrot, Bs.As., T. VII, pág. 331); inmediatamente se puede creer, que tales prerrogativas han sido puestas al solo efecto de perjudicar al demandado, sin embargo ellas han nacido a la luz del mismo desequilibrio que el juicio ejecutivo intrínsecamente posee, puesto que, al lado de su celeridad y de estas otras cuestiones, el demandado puede perfectamente promover un juicio ordinario y con el mismo, coartar la ejecución en concreto. Entonces, el equilibrio sistemático del instituto queda asegurado.-----

De todas maneras somos conscientes que existen Tribunales locales que se han visto proclives a la discusión de la causalidad de la obligación

dentro del trámite ejecutivo, y que es definitivamente hacia donde orienta el problema el recurrente, siempre que tal indagación -han dicho los nombrados Tribunales- no importe un desvirtuar groseramente la naturaleza procesal del juicio ejecutivo. Sin embargo somos de la opinión que ejecutarlo de dicho modo, es hacer igualmente que el juicio ejecutivo deje de ser el que es y si la ley le ha otorgado a priori, con plena abstracción la posibilidad de la discusión solo formal, no parece que pueda el intérprete en el hic et nunc, arrogarse la calidad de legislador.-----

Aunque con dureza, la jurisprudencia ha señalado que quedan al margen del juicio ejecutivo las denominadas cuestiones ético subjetivas (cfr. ED, T. 74-392) y que en la mayoría de los casos calan en la propia génesis del título ejecutivo.-----

Por último, sólo cabría agregar que ha sido lo indicado finalmente, lo que ha primado sobre el temperamento del propio legislador local, al sancionar recientemente el Código de Forma (Ley N° 8465), puesto que ha aspirado en manera inequívoca a que el juicio ejecutivo sea propiamente ejecutivo, pues por ello impide el art. 549 ib., que la excepción de inhabilidad de título planteada exceda el marco de los requisitos extrínsecos del título mismo, con lo cual y a contrario, resulta obvio que han sido alejadas todas las posibilidades de búsqueda del estudio causal en dichos pleitos.-----

En virtud de lo que se ha dicho, corresponde rechazar la apelación que ha sido deducida.-----

V.- Las costas deben imponerse a la parte demandada por resultar vencida (art. 130 CPC). Propongo entonces, que se regulen los honorarios a los letrados intervinientes, atento a las pautas cualitativas establecidas por el art. 36 del C.A. (incs. 1, 5 y 7) y de lo que fuera materia de

discusión en la Alzada (art. 37 ib.), corresponde regular los honorarios por los trabajos de la segunda instancia al Dr. Oscar Sánchez Brondo en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto medio que corresponda de la escala del art. 34 L.A. (arts. 34, 36, 37, 78 y 120 ley 8226).-----

Así voto.-----

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA NORA LLOVERAS A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA

DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el señor Vocal preopinante.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA PRIMERA CUESTION

PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el señor Vocal Dr. Armando Segundo Andruet (h), por ajustarse a derecho.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ARMANDO SEGUNDO ANDRUET (H) A LA SEGUNDA CUESTION

PLANTEADA DIJO: Propongo que: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el demandado en contra de la sentencia N° 18 del 1.III.01 confirmando la misma en todo cuanto resuelve.-----

II.- Imponer las costas a la demandada que resulta vencida, regulándose los honorarios al Dr. Oscar Sánchez Brondo en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto medio que corresponda de la escala del art. 34 L.A.-----

LA SEÑORA VOCAL DOCTORA NORA LLOVERAS A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA

DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el señor Vocal preopinante.-----

EL SEÑOR VOCAL DOCTOR ABRAHAM RICARDO GRIFFI A LA SEGUNDA CUESTION

PLANTEADA DIJO: Que adhiere en un todo al voto emitido por el señor Vocal Dr. Armando Segundo Andruet (h), por ajustarse a derecho.-----

Por el resultado de la votación precedente.-----

SE RESUELVE: I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia número dieciocho (N° 18) del primero de marzo de dos mil (1.III.01) confirmando la misma en todo cuanto resuelve. II.- Imponer las costas a la demandada que resulta vencida, regulándose los honorarios al Dr. Oscar Sánchez Brondo en el treinta y cinco por ciento (35%) del punto medio que corresponda de la escala del art. 34 L.A.- Protocolícese, hágase saber y bajen.

CAMARA QUINTA C. Y C. 2001-08-28

Cheques. Ley 24.452

Denuncia penal. Art. 63. Banco expide certificación para acciones civiles (arg. art. 38 Primer párrafo acción ejecutiva)

Orden de no pago al Banco girado. Diferencia con irrevocabilidad del cheque.

Relación interna (cliente-banco) y relación externa. Cheque realizado con constancia de no efectivizarse "orden de no pago" del librador

ANDRUET

LLOVERAS

GRIFFI